

Le fonds de commerce

Le fonds de commerce est une notion juridique qui peut être définie comme étant un ensemble d'éléments corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale.

La constitution d'un fonds de commerce, et la nature des éléments qui le composent, sont variables en fonction de l'activité exercée.

Le fonds de commerce est considéré comme un meuble par fiction juridique.

Le fonds de commerce est défini par l'article 115 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce comme étant « un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle ».

Le législateur Mauritanien traite le fonds de commerce dans les articles 115 à 196 du code de commerce. Il convient d'examiner, d'abord, les éléments du F.C, ensuite les contrats qui portent sur le fonds de commerce et les règles destinées à le protéger.

Le fonds de commerce apparait suivant le schéma qui suit :

Il faut trouver un local bien situé + le louer si le lieu ne vous appartient pas
+Attirer une clientèle + Développer son activité.

Section I- les éléments du fonds de commerce

Le fonds de commerce se compose d'éléments corporels et d'autres incorporels.

Sous-section I- les éléments corporels du fonds de commerce

D'après les dispositions de l'article 116 du code de commerce, les éléments du fonds de commerce se compose du « mobilier commercial, les marchandises et l'outillage »

- 1- **Le mobilier commercial** : c'est-à-dire tous les objets mobiliers comme les bureaux, les fauteuils, les chaises, les salons de réception, les comptoirs...
- 2- **les marchandises** : c'est l'objet même du commerçant, il s'agit de tous les produits et objets destinés à la vente. Mais, en cas de vente du F.C., les marchandises font normalement l'objet d'un inventaire et leur prix est fixé séparément.
- 3- **Les matériels et l'outillage** : Ces deux termes sont synonymes, ils se composent de l'ensemble des biens meubles affectés à l'exploitation du

fonds de commerce. Autrement dit, ils désignent tous les biens meubles, autres que le mobilier commercial, qui servent à l'exploitation du fonds, exemple : les appareils et machines, les moyens de transports...

Il faut noter cependant que ces éléments corporels n'ont pas toujours une importance dans un F.C., sauf par exemple les appareils et machines dans l'industrie, le mobilier dans le mobilier dans l'hôtellerie ou les véhicules de transport (bus et cars) dans le commerce de transport...

Par ailleurs, il existe bien des F.C. qui n'ont pas de marchandises telles que les fonds des courtiers et agents d'affaires....

Sur le plan d'appréciation, les éléments corporels du fonds de commerce sont secondaires et selon certains auteurs peuvent ne pas exister.

Sous- section II- les éléments incorporels du fonds de commerce

Si le fonds de commerce est considéré comme un bien, **sa nature juridique de bien incorporel ne peut être mise en doute.**

De ce fait, la prééminence des meubles incorporels sur les meubles corporels au sein du fonds de commerce est justifiée par l'importance accordée à la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce.

En effet, les éléments, incorporels du fonds de commerce peuvent être regroupés autour de la clientèle, le nom commercial, le droit au bail et le droit de la propriété industrielle.

1- la clientèle

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 116 du code de commerce, le fonds de commerce comprend la **clientèle** et l'**achalandage**. La différence entre ces expressions consisterait dans le fait que la clientèle serait composée des personnes attirées par les qualités personnelles du commerçant tandis que l'achalandage désignerait les personnes attirées par l'implantation de l'établissement commercial.

Il faut retenir que :

- Il n'y a pas de fonds de commerce là où il n'y pas ou plus de clientèle. L'absence de clientèle ou sa disparition entraînent celles du fonds.
- Le transfert du fonds suit le transfert de la clientèle. On ne saurait concevoir une cession de fonds, vente ou apport en société, sans cession de clientèle. Il n'est pas indispensable que tous les éléments soient cédés

de manière globale. Il suffit de céder les éléments qui attirent la clientèle pour que le fonds soit transmis du même coup. L'appréciation des différentes situations de fait revient aux tribunaux qui décideront en fonction de la nature de l'activité. Ainsi la cession par un commerçant de détail de son droit au bail vaut une cession de son fonds de commerce.

- Le fonds existe dès lors qu'il y a une clientèle et alors même qu'aucun autre élément ne peut être constaté (marchandise, droit au bail). Tel est le cas du courtier « ambulant ».

2- Le nom commercial

Le nom commercial sert à identifier le commerçant et son entreprise. C'est l'appellation sous laquelle le commerçant, personne physique ou morale, exerce son activité. Il est possible d'utiliser indifféremment un nom patronymique, un pseudonyme ou nom composé ou même une dénomination de fantaisie. Contrairement au droit civil, le nom commercial a une valeur patrimoniale. Le patronyme utilisé pour l'exploitation du fonds de commerce devient un élément de celui-ci cessible avec lui.

C'est ainsi que le nom commercial est devenu protéger par l'action en concurrence déloyale contre les imitations des concurrents qui pourraient être cause de confusion dans l'esprit de la clientèle.

3- Le droit au bail

Pour divers raisons, le commerce de détail est le plus souvent exercé dans un local loué. Or cette situation fait courir au commerçant le risque de perdre son fonds de commerce s'il est expulsé de son local. La protection du locataire commerçant est donc apparue nécessaire.

Ce droit n'a d'intérêt que dans le cas où le commerçant n'est pas propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce. Il exprime la protection accordée par le législateur aux locataires de locaux à usage commercial contre les éventuels abus des propriétaires des murs qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le commerçant. De plus, il est difficile de concevoir une vente d'un F.C sans local.

Le législateur mauritanien, organise les baux à usage commercial dans les articles **81-144** du code de commerce.

Le principe de ces articles est que le locataire du fonds de commerce a un droit au renouvellement de son bail qui fait partie indissociable du fonds.

Et si le bailleur refuse le renouvellement, il doit payer au locataire une indemnité d'éviction. Cette mesure voulue par le législateur, cherche un équilibre entre la liberté de jouissance des biens et le souci de protection de consommateur contre la disparition brutale du fonds.

Toutefois, le bail ne peut être soumis à ces règles que s'il porte sur un immeuble ou un local dont la destination est l'exploitation d'une activité commerciale. De même, le bénéfice de droit est réservé aux personnes inscrites au registre de commerce comme étant des commerçants.

4- La propriété industrielle

Les droits de propriétés industrielles sont multiples et variés. Ces droits, sont des droits incorporels portant sur des créations d'intelligence, qui confère à leurs titulaires un monopole d'exploitation ou d'utilisation, protégé légalement par des sanctions pénales et civiles.

Le droit de propriété industrielle en Mauritanie est régi, comme dans seize pays de l'organisation Africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) par l'accord de Bangui. Les droits de propriété industrielle, repose sur un principe de base commun, c'est le dépôt de la publicité permettant d'assurer la sécurité juridique à la fois des titulaires et des tiers.

Tous les droits de propriété industrielle peuvent faire partie du fonds de commerce, le plus comme parmi eux sont : les brevets d'inventions, les marques de fabriques et les dessins et modèles.

Section II- les opérations sur le fonds de commerce

Le fonds de commerce peut faire l'objet de divers opérations et notamment une vente, un nantissement et une location-gérance.

Sous- section I- la vente du fonds de commerce

Le fonds de commerce représente un bien transmissible comme tout autre bien, sa vente constitue une cession à titre particulier entre vifs.

La vente du fonds de commerce est minutieusement réglementés dans le souci de protégés tous les intéressés par le fonds à savoir : l'acquéreur, le vendeur, les créanciers, et le fisc. Il en résulte un formalisme excessivement lourd, car la vente de fonds de commerce est entourée des conditions particulières qui assurent sa loyauté et elle produit certains effets. Parmi ces conditions certaines sont relatives au fond de l'opération, d'autres à sa forme.

A- les conditions relatives au fond

Ce sont en principe, de tout contrat et spécialement de toute vente, il s'agit de :

- **Une capacité** pour le vendeur et l'acquéreur, la vente ou l'achat d'un fonds de commerce est un acte de commerce, qui ne peut être exercé par des non capables du fait particulier de l'activité et ses exigences ;
- **Le consentement** : les règles de droit commun concernant les vices du consentement (dol, erreur, violence) sont applicables à la vente du fonds de commerce, dès lors, celui-ci doit être exempt de tous vices pour la validité de la vente.
- **La cause** : en principe, elle ne pose pas de problème, particulier et elle est soumise au droit commun. Il est d'ailleurs très rare que l'absence de cause ou l'illicéité de cause soit soulevée en matière de vente de fonds du commerce et en contrepartie son prix.
- L'objet : il s'agit d'une part du fonds de commerce lui-même et d'autre partie le prix .

B- la condition de forme

Afin de protéger l'acquéreur, le code de commerce oblige le vendeur d'insérer certains renseignements dans l'acte même de vente. Par conséquent, la rédaction d'un écrit s'impose d'autant plus que l'omission de ces mentions rend l'acte annulable (comme Le nom du vendeur, L'état des inscriptions des privilèges, nantissements).

Mais l'écrit ne doit pas prendre obligatoirement la forme authentique, il peut être seulement sous-seing privé.

Sous-section II- le nantissement du F.C.

L'utilisation du F.C pour obtenir un crédit est devenue une opération courante. C'est une sorte de gage sans dépossession, parfois désigné sous le vocable d'hypothèque mobilière. Le nantissement de F.C est donc une sûreté réelle mobilière sans déplacement, c'est-à-dire sans transfert de possession, qui permet notamment lorsque le fonds a une grande valeur d'obtenir les crédits nécessaires au financement de son exploitation. Le nantissement de fonds de commerce est né de l'imagination de la pratique qui devait combiner l'idée de gage et l'absence de dépossession.

Le nantissement de fonds de commerce est donc une opération juridique qui permet à un créancier d'obtenir une garantie sur les biens constituant le fonds

de commerce. Il s'agit donc d'un acte de garantie qui permet au créancier d'avoir un droit de préférence sur les éléments du fonds de commerce en cas de défaillance du débiteur.

Sous- section III- la location gérance

Le législateur qui le règlemente dans ses articles 190 à 196 du code de commerce ne définit pas la location gérance. La doctrine à, cependant, définie la location gérance comme étant : tout contrat ou convention par lesquels le propriétaire du fonds de commerce en concède totalement ou partiellement l'exploitation, pour une période déterminée ou moyennant un loyer, à une personne, dénommée gérant, qui exploite le fonds loué à ses risques et périls. Elle constitue le fruit d'une dissociation de la propriété du fonds de son exploitation. A l'origine le contrat de location gérance était destiné à résoudre le problème d'une incapacité momentanée d'exercer le commerce affectant le propriétaire d'un fonds. La location gérance présente une utilité dans la mesure où elle permet, par exemple, à un mineur de conserver le fonds dont il a hérité et qu'il ne peut pas exploiter personnellement ; à un commerçant âgé ou malade d'en conserver la valeur en exploitant par l'intermédiaire du gérant et à celui-ci, de devenir un jour propriétaire à son tour d'un fonds de commerce.

1- Les conditions de la location-gérance

La loi ne prévoit aucune condition particulière, ce qui suppose que comme tout contrat, le contrat de la location gérance obéit aux conditions de droit commun à savoir la capacité, le consentement, l'objet et la cause.

L'objet du contrat constitué par le fonds de commerce et le loyer. On retrouve concernant l'exigence d'un fonds de commerce la condition relative à l'existence d'une clientèle réelle, certaine et personnelle. Le contrat qui aurait pour objet la location d'un local simplement aménagé en vue d'une certaine activité mais qui n'a pas encore été effectivement exploité est un bail d'immeuble et non un contrat de location-gérance. Il est à noter aussi qu'aucune condition de forme n'était exigée pour la validité de l'acte, mais l'écrit était néanmoins nécessaire en vue de la réalisation de formalités de publicités.